

1501036-35.2021.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ORLANDO GONÇALVES DE CASTRO NETO

Comarca: Agudos

Foro: Foro de Agudos

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 07/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2254482/2021 - DEL.POL.AGUDOS, 20321048 - DEL.POL.AGUDOS, 1204/21/101 - DEL.POL.AGUDOS, 2254482 - DEL.POL.AGUDOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GEOVANI BARBOSA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Agudos

Foro de Agudos

1ª Vara Judicial

Rua Paulo Nelli, 276, Agudos-SP - cep 17120-370

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

1501036-35.2021.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501036-35.2021.8.26.0594

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2254482/2021 - DEL.POL.AGUDOS, 20321048 - DEL.POL.AGUDOS, 1204/21/101 - DEL.POL.AGUDOS, 2254482 - DEL.POL.AGUDOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GEOVANI BARBOSA MUSSIO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ORLANDO GONÇALVES DE CASTRO NETO

Vistos.

Geovani Barbosa Mussio, vulgo "Salgado", qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 (fls. 193/195).

Consta da denúncia que, no dia 17 de setembro de 2021, por volta das 11h30, na Rua Paulo Coutinho, nº 503, Jardim Vienense, nesta cidade e Comarca de Agudos, o denunciado trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 16 (dezesesseis) pedras "crack", com massa líquida total de 2,78g (dois gramas e setenta e sete centigramas), conforme laudo definitivo acostado às fls. 180/185, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em 18 de novembro de 2021, houve determinação de notificação do acusado (fls. 196/221). Houve a notificação pessoal do réu (fls. 227) e foi apresentada defesa prévia através de Defensora nomeada (fls. 236). A seguir, a denúncia foi recebida e foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 239/240).

Em audiência de instrução, procedeu-se à oitiva das testemunhas, bem como, ao final, ao interrogatório do réu.

As alegações finais foram oferecidas oralmente e gravadas no sistema SAJ.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O feito encontra-se em ordem. Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais, pertinente a análise do mérito da causa.

No mérito, a pretensão punitiva deve ser julgada PARCIALMENTE PROCEDENTE, isso porque, terminada a instrução da causa, não restou devidamente comprovado nos autos que o acusado praticou o ilícito a ele imputado, mas sim o crime de porte de drogas para uso próprio (art. 28, Lei nº 11.343/06).

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 08/13), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), pelos laudos periciais (fls. 44/49 e 180/185), bem como pela prova oral produzida na fase instrutória sob o crivo do contraditório.

Quanto à autoria, necessária detida análise da prova oral produzida.

Dispõe o artigo 33 da Lei nº 11.343/06 que:

"Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa".

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o comércio ilícito. O objeto material é a droga; o jurídico é a saúde pública.

Em juízo, a testemunha e policial militar Ricardo Faustino Xavier declarou que as investigações começaram em 2020 a partir de denúncias de tráfico na casa do acusado. Fizeram toda a investigação, solicitaram a busca e apreensão, mas, antes da concessão, ele foi preso em flagrante e ficou preso. Só que apuraram que ele tinha ficado com dívida com um fornecedor de drogas e sua amásia continuou a traficância, sendo presa posteriormente. O réu ficou preso até 10 de agosto de 2021. Logo que saiu, receberam várias denúncias de que ele estaria novamente traficando. Apuraram que ele alugou um quarto na residência de Paulo Sérgio Pires. Fizeram diligências e verificaram que várias pessoas adentravam a casa e mantinham contato por janela que seria o quarto do réu. Foi pedida a busca e apreensão. Localizaram o réu e a testemunha Paulo próximos de sua casa. Chamaram reforço. Foram cientificados da busca. Em busca pessoal do réu, em seu bolso, localizaram uma pedra de crack. Dentro de sua carteira, havia mais 4 pedras de crack e cerca de R\$ 300,00 em dinheiro. Fizeram busca no quarto em que ele havia alugado. Em um compartimento, havia 12 pedras de crack embaladas. Na continuidade das buscas, na

mesma parede, havia uma blusa de moletom, onde havia uma sacola com 127 sacos plásticos vazios. Do lado da cama dele, havia uma caderneta com inúmeras anotações típicas de contabilidade de tráfico (valores, nomes etc). Conduziram o réu e Paulo à Delegacia. Paulo disse que o réu lhe pagava R\$ 600,00 por mês; e não sabia o motivo pelo qual as pessoas iam até lá, acreditava que era pelas tatuagens.

Ressalte-se, por oportuno, que os policiais não estão impedidos de depor pela legislação processual pátria. O fato de serem servidores comprometidos com a aplicação da lei, repressão e combate ao crime não retira a força de suas palavras. Pelo contrário, suas palavras têm pleno crédito até que prova manifesta em contrário exclua a presunção. Ademais, não há motivos para distinguir a validade do depoimento de policiais das demais provas orais produzidas em juízo, uma vez que eles, como quaisquer testemunhas, depõem sob compromisso, devendo ser presumida, por isso, a veracidade de suas informações, até que se demonstre cabalmente o contrário.

Da jurisprudência, trago à colação: “não há óbice a que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu sejam considerados na sentença como elemento de prova amparador da condenação, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de cognição, tal como na hipótese” (STJ, HC nº 162.131/ES, relator Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 25/05/2010).

No entanto, é pacífico meu entendimento jurisdicional, inclusive em Segunda Instância na 1ª Turma Criminal do Colégio Recursal da 1ª CJ - Santos, no sentido de que não basta uma testemunha policial para a condenação do acusado.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO. Interposição pela parte ré, ora recorrente. Sentença condenatória. Prova dos autos insuficiente à condenação. Oitiva de apenas um policial militar em fase judicial. Confirmação dos elementos colhidos no inquérito inviável sem reiteração judicial. Presença de outras testemunhas não indicadas que poderiam corroborar os fatos. O ônus probatório no processo, ainda que penal, deve ser tão intenso quando a capacidade da parte de dele se desincumbir. A prova produzida na fase de inquérito não tem aptidão para sustentar uma condenação. Uma vez iniciada a ação penal, as provas ontologicamente repetíveis coletadas na fase inquisitorial não servem para fundamentar a condenação, pois são uma prova precária produzida em sede policial sem o contraditório. São os atos de prova que podem fundamentar uma condenação, mas não os atos de investigação. Em um modelo garantista, em que devem ser respeitados os princípios e garantias da pessoa submetida ao processo penal a fim de evitar abusos estatais que interfiram em sua liberdade, dúvidas consideráveis devem ser resolvidas favoravelmente ao réu. Detendo o monopólio da força e, por via de consequência, do poder punitivo e do poder acusatório, compete exclusivamente ao Estado-Acusação comprovar, de forma suficiente e estreme de dúvidas, a autoria da conduta criminosa, não bastando a oitiva de apenas uma testemunha em fase judicial. Ante a fragilidade das provas, especialmente porque ouvida somente uma testemunha policial em juízo, inviável a condenação. Precedentes desta 1ª Turma Criminal do Colégio Recursal de Santos. Fragilidade probatória que conduz, por conseguinte, à absolvição do acusado nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal (CPP). RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 0004439-06.2019.8.26.0223; Relator (a): Orlando Gonçalves de Castro Neto; Órgão Julgador: 1ª Turma Criminal - Santos; Foro de Guarujá - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 19/10/2021; Data de Registro: 19/10/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO. Interposição pela parte ré, ora recorrente. Sentença condenatória. Prova dos autos insuficiente à condenação. Oitiva de apenas um policial militar em fase judicial. Confirmação dos elementos colhidos no inquérito

inviável sem reiteração judicial. Presença de outras testemunhas não indicadas na denúncia e que poderiam corroborar os fatos. Ademais, presença de outras testemunhas arroladas na denúncia, mas com desistência expressa de sua oitiva em audiência de instrução pela Acusação. O ônus probatório no processo, ainda que penal, deve ser tão intenso quando a capacidade da parte de dele se desincumbir. A prova produzida na fase de inquérito não tem aptidão para sustentar uma condenação. Uma vez iniciada a ação penal, as provas ontologicamente repetíveis coletadas na fase inquisitorial não servem para fundamentar a condenação, pois são uma prova precária produzida em sede policial sem o contraditório. São os atos de prova que podem fundamentar uma condenação, mas não os atos de investigação. Em um modelo garantista, em que devem ser respeitados os princípios e garantias da pessoa submetida ao processo penal a fim de evitar abusos estatais que interfiram em sua liberdade, dúvidas consideráveis devem ser resolvidas favoravelmente ao réu. Detendo o monopólio da força e, por via de consequência, do poder punitivo e do poder acusatório, compete exclusivamente ao Estado-Acusação comprovar, de forma suficiente e estreme de dúvidas, a autoria da conduta criminosa, não bastando a oitiva de apenas uma testemunha em fase judicial. Ante a fragilidade das provas, especialmente porque ouvida somente uma testemunha policial em juízo, inviável a condenação. Precedentes desta 1ª Turma Criminal do Colégio Recursal de Santos. Fragilidade probatória que conduz, por conseguinte, à absolvição do acusado nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal (CPP). RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1502567-56.2020.8.26.0477; Relator (a): Orlando Gonçalves de Castro Neto; Órgão Julgador: 1ª Turma Criminal - Santos; Foro de Praia Grande - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 22/02/2022; Data de Registro: 22/02/2022) [grifamos]

No entanto, houve a oitiva de mais uma testemunha, ainda que não policial, pelo que seu depoimento também deverá ser levado em consideração.

Vejamos.

Por seu turno, a testemunha Paulo Sérgio Pires contou que conhece o réu da Vila, que ele estava morando em sua casa, onde alugou um quarto. Só moravam a testemunha e o acusado, que ali estava há uns dois meses. O réu ainda não havia pagado nenhum aluguel. A estimativa era que pagasse por mês R\$ 600,00. Acompanhou a busca e apreensão. Os policiais encontraram as drogas dentro da casa da testemunha. Não sabe o local exato porque estava algemado junto com o réu. As drogas foram achadas no quintal e na carteira dele. Não viu o encontro de drogas no quarto do réu.

De sua análise, verifica-se que em nada acrescentou em termos de prova em favor da Acusação, senão que infirmou a própria busca e apreensão na medida em que afirmou ter ficado algemado na viatura durante a busca em sua casa.

Em solo policial, o acusado optou por permanecer em silêncio (fls. 06).

Interrogado em juízo, o réu Geovani Barbosa Mussio contou que os fatos são falsos. Disse que tinha 5 pedras de crack que tinha acabado de comprar para fumar. Desconhece as demais 11 pedras que os policiais encontraram.

Como se denota, à luz do arcabouço probatório constante dos autos, verifico que a condenação do acusado por tráfico de drogas não se sustenta.

De início, em relação às 16 pedras de crack encontradas, entendo que não foram produzidas provas suficientes para vincular a substância ao acusado no sentido de que as teria consigo e em seu quarto para fins de traficância e não para uso próprio.

Os policiais civis referem-se a denúncias anônimas de que o acusado praticaria tráfico de drogas. Tais indícios, contudo, são frágeis e insuficientes para

vincular as drogas à pessoa do acusado, servindo, quando muito, para deflagrar uma investigação, o que foi feito, com a realização de busca e apreensão deferida judicialmente, a qual, no entanto, revelou pequena quantidade de droga, insuficiente para denotar traficância.

Ora, havia a possibilidade da produção de outras provas. Isso porque o ônus probatório no processo, ainda que penal, deve ser tão intenso quando a capacidade da parte de dele se desincumbir. Por conclusão, exige-se um ônus probatório menor naqueles crimes ocultos, cometidos na clandestinidade; exige-se um rigor probatório maior naqueles crimes cometidos à vista de testemunhas. Não sem razão, dispõe o art. 6º, inciso III do Código de Processo Penal determina: "Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá: (...) colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias".

No caso em apreço, chama a atenção ao seguinte ponto: tendo sido noticiada a existência de denúncias em desfavor do acusado, ainda que anônimas, nenhum registro dessas denúncias veio aos autos. Se isso não ocorreu, não se pode relativizar e reduzir o ônus probatório da Acusação em prejuízo do acusado.

Por outro lado, a prova produzida na fase de inquérito não tem aptidão para sustentar uma condenação. Uma vez iniciada a ação penal, as provas ontologicamente repetíveis coletadas na fase inquisitorial não servem para fundamentar a condenação, pois são uma prova precária produzida em sede policial sem o contraditório.

A prova produzida na fase inquisitorial serve tão somente para subsidiar o convencimento do órgão acusador e permitir o oferecimento da denúncia, salvo se irrepetível. O Poder Judiciário existe e justifica-se em função da garantia à Jurisdição: como seu consectário lógico, exsurge a garantia de ser julgado com base na prova produzida dentro do processo, com todas as garantias do devido processo penal.

São atos de prova os atos dirigidos a convencer o juiz de uma afirmação para o julgamento final, no processo e a serviço do processo e da sentença, exigindo a estrita observância à publicidade, contraditório e imediação, praticados sob a visão e a supervisão do Juiz de Direito. Por outro lado, são atos de investigação aqueles dirigidos não a uma afirmação, mas a uma hipótese; estão a serviço da investigação preliminar e servem para formar um juízo de probabilidade – não a convicção do juiz; não exigem observância da publicidade, contraditório e imediação, princípios que podem ser restringidos; servem à formação da opinião delicti do acusador, demonstrando o *fumus comissi delicti* para justificar o processo (recebimento da ação penal) ou o não processo (arquivamento) e são praticados pelo Ministério Público ou polícia judiciária. São os atos de prova que podem fundamentar uma condenação, mas não os atos de investigação.

Em que pese a gravidade dos fatos imputados, isso não é razão suficiente para assumir o risco do erro judiciário em que consistiria a condenação no presente caso, pois o conjunto probatório é demasiadamente frágil. Nisso consiste o mandamento de otimização contido no princípio do *in dubio pro reo*. Em um modelo garantista, em que devem ser respeitados os princípios e garantias da pessoa submetida ao processo penal a fim de evitar abusos estatais que interfiram em sua liberdade, dúvidas consideráveis devem ser resolvidas favoravelmente ao réu. Assim ensina LUGI FERRAJOLI ao concluir que "A certeza perseguida pelo direito penal mínimo está, ao contrário, em que nenhum inocente seja punido à custa da incerteza de que também algum culpado possa ficar impune" (Direito e Razão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 85).

Por conseguinte, em relação às 16 pedras de crack encontradas na posse do acusado e

no quarto que alugava, entendo que não foram produzidas provas suficientes para afastar, com a segurança que uma condenação exige, a possibilidade de as substâncias se destinarem exclusivamente ao consumo do réu, como por ele afirmado.

Ao contrário, o que verifico de seus antecedentes (fls. 113/118) são diversas condenações por furto e receptação, ou seja, crimes patrimoniais, o que se revela comum para usuários de droga pobres, que recorrem à criminalidade patrimonial como forma de, com o produto financeiro do crime, adquirirem mais entorpecente para satisfazer o odioso vício. Além disso, verifico que as denúncias pretéritas por tráfico contra o acusado ou foram julgadas improcedentes, com sua absolvição, ou foram desclassificadas para o crime de porte de drogas para uso próprio, o que reforça a conclusão aqui estabelecida.

Ora, se os antecedentes podem – e são rotineiramente – utilizados contra o réu para justificar condenações baseando-se numa reiteração comportamental, podem – e devem – ser utilizados em casos de absolvição ou desclassificação. Entendo, baseado no quadro probatório deficitário produzido nestes autos e na folha de antecedentes do acusado, que não passa de um adicto, possuindo drogas para uso próprio, bem como, vez ou outra, praticando pequenos furtos para sustentar o próprio vício, mas sem qualquer relação com o hediondo crime de tráfico de entorpecentes.

De mais a mais, na linha da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 é tipo incongruente, ou seja, o tipo subjetivo está além do tipo objetivo, o que equivale a dizer que se exige o elemento subjetivo específico de consumir a droga que porta.

Em outros termos, para a condenação no delito do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, e não no artigo 28, exige-se que se afaste, com segurança, a finalidade do consumo próprio (REsp n. 1134610/MG, rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, j. 19.08.2010). Apenas quando afastada essa possibilidade, com segurança, será possível a condenação no tipo do tráfico de drogas, esse sim congruente simétrico, em que o tipo objetivo coincide com o tipo subjetivo, não se exigindo o elemento subjetivo.

Na espécie, verifico que remanesce dúvida razoável acerca da destinação que o acusado pretendia dar a droga com ele apreendida, não sendo possível afastar com certeza a finalidade de consumo próprio.

Em que pese ser valoroso o depoimento dos policiais civis, não têm valor absoluto. É verdade que, sem pretender qualquer crítica, sabe-se que a atuação policial é uma atividade administrativa que se situa em um contexto de tensão de direitos fundamentais, de modo que seria ingenuidade recorrer acriticamente ao dogma da presunção de regularidade dos atos dos agentes dos poderes públicos, confundindo vigência (existência do ato e regularidade formal) com validade (conteúdo material constitucionalmente conformado).

Nesse sentido, LUIGI FERRAJOLI destaca que “diversamente dos outros ramos da administração pública, é uma atividade em contato direto com as liberdades fundamentais” (Diritto e Ragione. 1998, p. 798, em tradução livre).

No caso concreto, a natureza e a quantidade da droga são perfeitamente compatíveis com a finalidade de consumo próprio. Observe-se que a quantidade de droga encontrada com o réu não excede ao que é típico para um usuário.

Ademais, não há prova de mercancia da droga, o que, apesar de não ser essencial ao tipo do tráfico, conferiria segurança para afastar a finalidade do exclusivo uso.

Com essas observações, é mesmo caso de DESCLASSIFICAR a imputação do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 para o artigo 28 da mesma Lei com relação às 16 pedras

de crack encontradas na posse do acusado e em sua habitação.

O acusado esteve preso durante o processo. O tempo de prisão preventiva é mais severo e gravoso do qualquer reprimenda que poderia ser imposta em caso de condenação pelo delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se, neste caso, o reconhecimento do exaurimento do direito de exercício da pretensão punitiva como forma de reconhecimento, pelo Estado, da prática de coerção cautelar desproporcional no curso do processo em desfavor do acusado (HC n. 390038/SP, rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, v.u., j. 06.02.2018). Essa decisão também não configura reincidência, com fundamento no mesmo julgado da Corte Federal.

Diante do exposto, RESOLVO o mérito da ação penal e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para DESCLASSIFICAR a imputação penal do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 para o artigo 28 da mesma Lei nº 11.343/06, bem como, por conseguinte, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado Geovani Barbosa Mussio, vulgo "Salgado", devidamente qualificado nos autos, por aplicação da detração penal analógica virtual, pois qualquer pena aplicável estaria fatalmente cumprida, nem havendo justa causa ou interesse processual para o prosseguimento do feito, com fundamento do artigo 109 da LEP.

Ante a improcedência, REVOGO a prisão preventiva ou domiciliar, bem como quaisquer medidas cautelares fixadas em desfavor da parte ré.

Portanto, expeça-se alvará de soltura clausulado.

Se for o caso, EXPEÇA-SE certidão para remuneração do Defensor dativo, conforme tabela do convênio DPE/OAB.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Sentença prolatada em audiência, saem as partes intimadas.

Publique-se e Cumpra-se.

Dispensado o registro (Provimento CG nº 27/2016).

Agudos, 07 de abril de 2022.

ORLANDO GONÇALVES DE CASTRO NETO
JUIZ DE DIREITO TITULAR

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA